

1500114-29.2022.8.26.0280

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS PINHEIRO e outro

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra VINICIUS PINHEIRO e ANDRE LUIZ MUNIZ SANTOS, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri (SP) - cep 11760-000

1500114-29.2022.8.26.0280 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500114-29.2022.8.26.0280

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS PINHEIRO e outro

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra VINICIUS PINHEIRO e ANDRE LUIZ MUNIZ SANTOS, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.

Sustenta a denúncia que, em 19 de abril de 2022, por volta das 17h00, na Estrada Manoel Francisco de Carvalho, 1, Rua Dois, na cidade de Pedro de Toledo e nesta comarca de Itariri, VINICIUS e ANDRE vendiam, guardavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 697,71 gramas de cocaína acondicionado em 1 invólucro, 1008,43 gramas de cocaína acondicionadas em 745 invólucros, 85,49 gramas de maconha acondicionadas em 29 invólucros, 64,21 gramas de crack acondicionadas em 77 invólucros, 155,35 gramas acondicionadas em 423 invólucros.

Sustenta ainda que VINICIUS e ANDRE LUIZ, anteriormente ao dia 19 de abril de 2022, em horário e local incerto, na cidade de Pedro de Toledo, nesta comarca de Itariri,

previamente ajustados, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/06).

Por fim, sustenta que no dia 19 de abril de 2022, por volta das 17h00, na Estrada Manoel Francisco de Carvalho, 1, RUA DOIS, na cidade de Pedro de Toledo e nesta comarca de Itariri, VINICIUS tinha em depósito 2 armas de fogo de uso permitido, sem autorização legal, devidamente descritas no auto de exibição e apreensão às fls. 14/15.

Narra que policiais civis, durante investigação para combater tráfico ilícito de entorpecentes no bairro Água Parada, valendo-se de campana e disfarce para acompanhar a movimentação dos suspeitos, lograram êxito em identificá-los como VINICIUS e ANDRÉ. Verificou-se que ANDRÉ era o vendedor dos entorpecentes, ao passo que VINICIUS exercia a função de gerente. Durante a investigação, os Policiais Civis acompanharam VINICIUS que se retirou do ponto de venda das drogas e se dirigiu para dentro do bairro, momento em que os policiais seguiram em seu encalço até chegarem em um sítio, onde aguardaram até que ele saiu e retornou para o ponto de vendas. No local, retirou um objeto e entregou para ANDRE, foi quando os policiais realizaram a abordagem de ambos, encontrando em busca pessoal certa quantidade de ilícitos. Neste momento, VINICIUS confessou que no sítio também havia guardado uma quantidade de drogas. Os policiais dirigiram-se até o local e lá localizaram grande quantidade de drogas, além de armas e outros objetos relacionados a traficância. Interrogado, ANDRE alegou que estava com cinco pinos de cocaína e uma pedra de crack para consumo próprio (fls. 4). Interrogado, VINICIUS confessou a traficância e que guardava as drogas no sítio, próximo ao local de vendas (fls. 5). Laudo pericial às fls. 136/139 e requisição do laudo pericial referente às armas apreendidas às fls. 19. Foram apreendidos caderno com anotações de controle das vendas dos ilícitos e coisas típicas destinadas a guardá-los para venda, havendo indícios de habitualidade na traficância, o que aponta para uma associação ao tráfico entre os denunciados, que exerciam funções típicas de associação criminosa. Além disso, foram apreendidos outros bens: 4000 eppendorfs para armazenar entorpecentes, R\$ 65,00, 2 balanças medidoras, 4 rádios transmissores, duas armas de fogo, dentre outros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação preliminar de fls. 16/17 e laudo pericial conclusivo às fls. 136/139. Por fim, a quantidade e diversidade de drogas encontradas, com alto poder alucinógeno e viciante, a forma como estavam embaladas, prontas para a venda, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, corroboram que as drogas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão em flagrante de ANDRE foi convertida em preventiva (fls. 102/105) e concedida liberdade provisória a VINICIUS.

Notificados, os réus apresentaram defesa (fls. 168/173) e a denúncia foi recebida (fls. 149/151).

Laudo de constatação a fls. 16/17 e laudo toxicológico definitivo a fls. 136/139.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado ANDRE diz ter ido, no dia, comprar droga de VINICIUS na Rua Um e foi usar na Rua Dois, estando apenas com 5 pinos de cocaína e 1 pino de crack quando detido pela polícia; conhecia VINICIUS de vista, de vê-lo na rua. Já o acusado VINICIUS confessou que estava vendendo a droga já há um mês, na rua, mas apenas parte do que foi apreendido era seu, 7 pinos de cocaína e 6 pedras, a fim de vende-las a terceiros, sem qualquer envolvimento de ANDRE, que foi comprar a droga, e sem conhecer o estoque da droga apreendido no sítio.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento parcial da pretensão acusatória, com a condenação de ambos pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, afastando-se a figura privilegiada ante a quantidade de droga, pela condenação de VINICIUS, mas com a absolvição pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, com valorização na fixação da pena da grande quantidade de munições (posse de arma) e dos maus antecedentes de ANDRE (fls. 253/261).

A defesa técnica foi pela absolvição do acusado ANDRE, que é mero usuário de drogas; pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão em relação a VINICIUS.

As folhas de antecedentes atualizadas foram acostadas a fls. 75/77 e 79/94 e há certidões de distribuição a fls. 96/97 e 98/100.

Fundamentação

Crime do artigo 35 da Lei 11.343/06

Diante da manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, pugnando pela absolvição do acusado, não há como acolher a pretensão acusatória inicialmente apresentada.

Segundo se entende, o sistema processual penal brasileiro tende ao modelo acusatório, conforme opção inequívoca da Constituição Federal e corolário do Estado Democrático de Direito, da estrutura e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e, sobretudo, da imparcialidade do juiz. Diante da manifestação do titular da ação penal, após o esgotamento da fase instrutória, impõe-se a absolvição quanto a esta imputação.

Crime do artigo 12 da Lei 10.826/03

A existência do delito, segundo se entende, não restou demonstrada.

A imputação inicial é de que o acusado VINICIUS manteria em depósito duas armas de fogo, contudo, não veio aos autos qualquer indicativo de sua existência. Embora o policial Carlos Henrique tenha mencionado a apreensão de revólveres, na fase policial ambos mencionaram apenas terem localizado “uma sacola contendo 18 munições de calibre 38 e 22” (fls. 02/03), justamente o que foi consignado no auto de apreensão (fls. 14/15). Nada indica, então, possuir o acusado dois revólveres no sítio em que guardava a droga – como se verá adiante.

Em suma, a este respeito, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto a este aspecto da responsabilidade penal do acusado. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se o afastamento da pretensão neste particular.

Crime do artigo 33 da Lei 11.343/06

A existência e a autoria delitivas restaram demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína, assim 745 porções individuais de cocaína, 29 porções individuais de maconha, 77 porções individuais de crack e 423 porções individuais de cocaína, com massa líquida de 311,6g, 70,4g, 26,1g e 121,2g, respectivamente.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por

episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscaram atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal), ainda que parcial.

Com efeito, os policiais civis atestaram ter realizado campanha visualizando a manutenção da droga em um sítio por VINICIUS, que a trazia para ser comercializada por ANDRÉ.

O policial civil João Paulo disse que no dia dos fatos foram ao Município de Pedro de Toledo para apreender o tráfico de drogas e em ponto já conhecido visualizaram dois indivíduos. ANDRÉ estaria atendendo os usuários, com uma sacola preta na mão da qual tirava algo e a entrega a terceiros, recebendo em troca algum coisa, em transação típica do comércio. Posteriormente, ANDRÉ se aproximou e VINICIUS, que entregou uma sacola a ANDRÉ, que voltou a atender usuários. VINICIUS saiu do local e foi seguido por um dos policiais à paisana, até que entrou em um sítio. Saiu de lá e retornou ao local (imediações de uma mercearia) em que estava ANDRÉ, entregando nova sacola que carregava dentro de suas vestes. Abordaram, primeiro, VINICIUS, localizando porções de maconha e de crack, dinheiro e uma chave residencial. Aproximando-se de ANDRÉ, este percebeu a abordagem e jogou uma sacola (com cocaína e crack) e fez a menção de correr, mas foi detido. Informalmente, ANDRÉ negou a traficância e disse ser usuário, mas VINICIUS confessou traficar, posteriormente confirmando, ainda, que o sítio era usado para guardar droga. Lá encontraram mais droga e munições. VINICIUS guardava a droga no sítio e fazia o abastecimento da biqueira, para que ANDRÉ vendesse a terceiros. Não conhecia os acusados antes da abordagem, mas, depois, viu que ANDRÉ já tinha passagem. A maior

quantidade da droga foi encontrada no sítio, cuja chave estava com VINICIUS. Informalmente, VINICIUS disse que não conhecia o dono do sítio – o qual o depoente está tentando, ainda, identificar, mas sem sucesso. Encontraram embalagens vazias de droga, mais de mil, além de rádio comunicador, balança e um caderno com anotações – das quais não se recorda com precisão, em detalhes. Outras equipes já conheciam o local como ponto de venda de drogas. Havia um pouco de movimento no ponto de drogas, na estrada/avenida, ficando a uma distância de cerca de 50m. Toda a campana foi feita no mesmo dia, num tempo total de cerca de 30 minutos. A entrada no sítio se deu com a autorização de VINICIUS, que possuía a chave.

O policial civil Carlos Henrique disse que foram ao conhecido ponto de tráfico em Pedro de Toledo, com viatura descaracterizada, e conseguiram identificar duas pessoas: ANDRÉ, que efetivamente estava na venda, e VINICIUS, sentado nas imediações. Visualizaram três transações com ANDRÉ. VINICIUS se ausentou e adentrou, após uma estrada de terra, um sítio, retornando depois para perto de ANDRÉ e lhe entregou uma sacola. Depois, VINICIUS confessou que estava guardando a droga e que ANDRÉ comercializava a droga. Apreenderam por volta de 4.000 tubos vazios de droga, grande quantidade de eppendorfs pronto para venda, além de crack e maconha, revólveres e munições. Foi apreendido um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, mas não se recorda de seu exato teor. Apreenderam 4 rádios comunicadores. Não conhecia ANDRÉ ou VINICIUS. VINICIUS gerenciava o comércio, abastecendo ANDRÉ e supervisionando as transações. Estava a cerca de 30-50m do acusado. No dia dos fatos, havia poucas pessoas passando pelo local, uma ou duas no máximo; não sabe dizer se é muito movimentado, mas usuários lá frequentam. Toda a campana foi feita no mesmo dia, num tempo total de cerca de 30-40 minutos. A entrada no sítio se deu com a autorização de VINICIUS, que possuía a chave e foi persuadido a colaborar diante de toda a evidência então já coletada.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. *mutatis mutandis* HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com a confissão parcial havida, como se disse, e com as circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante. E nada há a indicar qualquer irregularidade na atuação policial.

Particularmente quanto a ANDRÉ, não se pode ignorar que, além de condenação anterior por delito a mesma natureza, ao que se tornará adiante, recentemente foi denunciado e condenado por este juízo também pelo tráfico de drogas, com flagrante por policiais militares de 2 de janeiro de 2021, estando, na época do fato presente, em gozo de liberdade provisória (autos nº 1500014-19.2021.8.26.0633). Tudo o que corrobora a versão policial.

Conclui-se, então, que não apenas a droga que era portada por VINICIUS e por ANDRÉ

no momento da prisão, mas também aquela mantida no sítio deve ser considerada como integrante da figura delitiva, aliás efetivamente visualizados atos de comércio. Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Uma vez que o acusado ANDRE é reincidente, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não exigindo a lei que a reincidência seja específica para afastar o redutor.

De qualquer modo, no caso, vê-se que o acusado já havia sido condenado, com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao caso vertente, nos autos nº 0003942-43.1999.8.26.0562, 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos, crime do art. 157, § 2º, I e II, em 25/04/1999, com trânsito em 03/03/2000 e cumprimento da pena previsto para setembro de 2022; nos autos nº 0000540-83.2007.8.26.0590, 1ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente, crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e do art. 333, em 11/01/2007, com trânsito em 27/02/2009 e cumprimento da última pena previsto para agosto de 2020, respectivamente. Há, ainda, condenação inicialmente substituída por restritiva de direitos, aparentemente com conversão, nos autos nº 0001993-42.2003.8.26.0562, 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos, por fato de e com trânsito em 01/12/2004 e cumprimento da pena previsto para setembro de 2024. Embora por fatos ocorridos já há muito tempo, o acusado não teve extintas as penas impostas há mais de 5 anos, razão de se reconhecer a reincidência (artigo 64, inciso I, do Código Penal), antes que meros maus antecedentes. Seja como for, a aplicação da figura privilegiada exige, cumulativamente, que o acusado seja portador de bons antecedentes.

Quanto a VINICIUS, a acusação não logrou demonstrar que o agente seja reincidente, tenha maus antecedentes, se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual aplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Ao contrário, o único elemento nesse sentido foi a folha de antecedentes, que indica a primariedade do acusado.

Note-se que a apreensão de quantidade não módica de droga em poder do acusado não é indício suficiente para, isoladamente, permitir se conclua que o acusado se dedica às atividades criminosas, pois daí não se extrai conclusão segura (STF, HC 138138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016), a menos que se trate de quantidade realmente exorbitante ou que haja outros indícios, o que não é o caso.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, os réus eram maiores de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, os réus tinham ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. Os acusados não ostentam maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social dos acusados, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social dos acusados, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade dos acusados, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas negativamente, diante da quantidade expressiva, superior ao suprimento anual de um usuário de droga, nos termos já adotados.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social, desfavorável a natureza e quantidade da droga e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 10 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena de VINICIUS em razão da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal), ainda que parcial ou

qualificada (cf. STJ, AgRg no AREsp 1763911/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021), pois prepondera, aqui, a colaboração com a apuração criminal e a certeza do julgamento em detrimento do arrependimento e penitência pelo crime. Deixo de valorar negativamente a reincidência de ANDRE, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se o bis in idem.

Por conseguinte, mantenho a pena-base de ANDRE e atenuo a pena de VINICIUS em 1/3 sobre o intervalo de pena em abstrato, que vai para 6 anos e 8 meses de reclusão. Por fim, na terceira etapa, reduzo a pena de VINICIUS de 2/3, no patamar máximo do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, do qual não se extrai critério seguro para gradação, em ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal), evitando-se, ainda, inadmissível bis in idem na dupla valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal combinado com o artigo 42 da Lei 11.343/06) na primeira e na terceira etapas.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade de VINICIUS em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e de ANDRE em 10 anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 1.000 dias-multa, fixo a pena de multa final de ANDRE em 1.000 dias-multa e de VINICIUS em 222 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica dos acusados, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Já não fosse a reincidência, mas em razão da condenação a pena de reclusão superior a 8 anos, fixo para ANDRE o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Já para VINICIUS, diante da condenação a pena igual ou inferior a 4 anos, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais que não se mostram desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal).

É inaplicável ao tráfico privilegiado a previsão constante do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, porque não se trata de crime equiparado a hediondo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), ao que se curvou o Superior Tribunal de Justiça revendo a tese fixada em recurso repetitivo e cancelando a sua Súmula 512, para assentar que "o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo" (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Substituição e sursis

Para ANDRE, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o

requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 4 anos, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal). Quanto a VINICIUS, diante das circunstâncias judiciais em torno do crime e do acusado (artigos 44, inciso III, e 59, inciso IV, do Código Penal) e do preenchimento dos requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade superior a 1 ano por duas restritivas de direitos, na forma do artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal, lembrando que o Senado Federal suspendeu a execução, nesta parte, da vedação disposta no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 após decisão do Supremo Tribunal Federal.

A fim de atender às finalidades preventiva e retributiva da sanção penal e permitir, na medida do possível, a restauração dos efeitos do delito na comunidade, determino a substituição por prestação de serviços à comunidade ou a entidades pública (artigo 46 do Código Penal), a ser especificada e adaptada quando da execução (artigos 148 e 149 da Lei de Execução Penal), e na limitação de fim de semana do artigo 48 do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade, conforme dispuser o juízo da execução.

Indicada a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP), é incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP), até porque aquela se mostra mais propícia à rápida ressocialização do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar ANDRE LUIZ MUNIZ SANTOS à pena de reclusão de 10 anos, em regime inicial fechado, e a 1.000 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; condenar VINICIUS PINHEIRO à pena de reclusão de 2 anos, 2 meses e 20 dias, em regime inicial aberto, e a 222 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de diminuição do parágrafo 4º do mesmo dispositivo, substituída pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana; absolvê-los da imputação da prática dos crimes do artigo 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; e absolver VINICIUS PINHEIRO da imputação da prática dos crimes do artigo 12 da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e mantenho a prisão preventiva de ANDRE. Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tais requisitos subsistem de forma ainda mais nítida.

Assim, recomendo o acusado ANDRE à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (artigo 8º da Resolução CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os réus ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Itariri, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA